

1501172-51.2022.8.26.0544
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: Renata Marques de Jesus
Comarca: Francisco Morato
Foro: Foro de Francisco Morato
Vara: 1ª Vara
Data de Disponibilização: 25/08/2022
... Franco).

No mesmo sentido:

“O crime de tráfico de entorpecentes é configurado ainda que não haja venda de tóxico, mas evidenciada somente a posse do produto destinado a consumo de outrem. Configurando crime de perigo abstrato, o tráfico não exige efetiva oferta da droga a terceiro, pois o bem jurídico tutelado é a saúde pública. É condenável a simples possibilidade de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Francisco Morato
Foro de Francisco Morato
1ª Vara
Rua João Mendes Júnior, 626, Francisco Morato - SP - cep 07910-220
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501172-51.2022.8.26.0544 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1501172-51.2022.8.26.0544
Classe - Assunto
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
MARCELINO ALVES FERREIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Renata Marques de Jesus

Vistos.

MARCELINO ALVES FERREIRA, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso nas penas do artigo 33, “caput”, da lei nº 11.343/06, porque no dia 02 de maio de 2022, por volta das 11h30, na Rua Honduras, altura do nº 113, bairro Jardim Buenos Aires, cidade e comarca de Francisco Morato, trazia consigo, para fins de tráfico, 90 (noventa) porções de “maconha” (cannabis Sativa L.), com peso líquido aproximado de 104,60g (cento e quatro gramas e sessenta centigramas); 13 (treze) porções de cocaína, com peso líquido aproximado de 6,72g (seis gramas e setenta e duas centigramas); e 165 (cento e sessenta e cinco) porções de crack, com peso líquido aproximado de 22,84g (vinte e duas gramas e oitenta e quatro centigramas), substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (fls. 1/3).

Preso em flagrante delito (fls. 4), em audiência de custódia foi concedido o benefício da liberdade provisória (fls. 33/34).

Notificado (fls. 94/95) o réu apresentou defesa prévia (fls. 71/77) e a denúncia foi recebida (fls. 84/85).

Durante a instrução processual foram ouvidas duas testemunhas arroladas pelas partes (fls. 116/117) e, ao final, o réu foi interrogado (fls. 118). Mídias arquivadas.

Em debates o Ministério Público pugnou pela procedência do pedido, com possibilidade de aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33, da lei nº 11.343/06 e fixação de regime semiaberto (fls. 113/115). A Defesa, por sua vez, requereu a absolvição e, subsidiariamente, a aplicação da pena no mínimo legal, aplicação da atenuante da confissão, reconhecimento da redução contida no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas em sua fração máxima e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, com fixação de regime inicial aberto (fls. 124/125).

É o relatório.

Fundamento e decido.

À luz das provas carreadas aos autos a pretensão inicial merece prosperar.

A materialidade restou comprovada ante o auto de prisão em flagrante (fls. 4), boletim de ocorrência (fls. 8/10), auto de exibição e apreensão (fls. 14), laudos de constatação provisória (fls. 18/23), além do exame químico-toxicológico de fls. 110/112, que constatou as presenças de tetrahidrocannabinol (THC) e de cocaína nas amostras analisadas.

A autoria também é certa, corroborada pela própria confissão (fls. 7 e 118).

Na fase extrajudicial o réu confessou os fatos, dizendo que trabalha como ajudante de pedreiro, é usuário de drogas e de bebida alcoólica e, na data dos fatos, estava traficando havia dois dias, iniciando as atividades às 07h e finalizando no período noturno, auferindo em torno de R\$ 100,00 (cem reais) por dia de trabalho. Não soube informar o nome do rapaz que recolhe o entorpecente e efetua o pagamento (fls. 7). Em juízo disse ter 44 anos de idade, ter três filhos menores, morar em casa própria, trabalhar limpando terreno e ajudante, com renda aproximada de R\$ 70,00 por dia, não conhecer as testemunhas arroladas e já ter sido processado criminalmente por furto, mas absolvido. Sobre os fatos, confirmando suas declarações anteriores, contou que no primeiro dia ficou de campana, como olheiro. No segundo dia foi preso. Estava com "o negócio no bolso". Estava de costas e falou "perdi, perdi". Não tentou correr. Iria "assumir o horário e deu esse desacerto". A droga em seu bolso tinha sido passada pelos outros (fls. 118).

Letícia Spindola Ventavoli, policial militar que participou da ocorrência, afirmou em solo policial que na companhia de seu colega realizava patrulhamento de rotina pelo local dos fatos, ocasião na qual dois após visualizarem a viatura se evadiram, sendo que um terceiro indivíduo não conseguiu empreender fuga. Realizaram a abordagem e o réu confessou a traficância, sendo encontrado no bolso de sua 24 (vinte e quatro) porções de maconha ;13 (treze) porções de cocaína e o valor de R\$ 16,00 (dezesseis) reais e, em uma bolsa localizada no chão, à sua frente, foi encontrada a quantidade de 165 (cento e sessenta e cinco) porções de crack e 66 (sessenta e seis) porções de maconha (fls. 5). Em juízo relatou que estava em patrulhamento de rotina e ao adentrar a via dois indivíduos correram. O réu não conseguiu e com ele havia entorpecente e dinheiro. Ele confessou o trafico no local. Na frente dele havia uma bolsinha com mais entorpecentes. No bolso dele tinha maconha e cocaína, além de dinheiro. Na bolsinha havia também crack. Era uma bolsa preta, marca "oakley", parecendo-se muito com aquela de fls. 109. Não

conhecia o réu antes dos fatos. O acusado admitiu ser sua a bolsa encontrada. O local é conhecido como ponto de tráfico. Não se recordou da quantia em dinheiro. A maior quantidade de droga era de crack e estava na bolsa. O acusado estava de costas e ao se virar já se deparou com a viatura (fls. 116).

Na mesma esteira o depoimento extrajudicial do também policial militar Alex Clayton Valentim do Rosario (fls. 6), que em juízo narrou que o local é conhecido pelo tráfico de entorpecentes. É uma rua sem saída e ao adentrar na via o réu servia um entorpecente para outros dois indivíduos. Ele estava de costas e não viu a viatura. Os dois correram e ele tentou empreender fuga, mas foi segurado. Com ele havia entorpecentes no bolso. Uma bolsa no chão tinha mais drogas. O acusado, que não conhecia, confirmou que estava no tráfico. Estava desempregado e era usuário. Na bolsa tinha mais droga. Havia maconha, cocaína e crack. Tinha dinheiro também, sem se recordar a quantia. As drogas que estavam com o réu e na bolsa eram do mesmo tipo de invólucro. A bolsa estava bem próxima do réu, "cerca de um passo". Havia um banco, com guarda sol. O acusado disse que ganhava uma porcentagem sobre o que vendia e que tinha começado o trabalho naquele dia. Acrescentou que a quantia de droga que estava na bolsa era maior do que aquela que estava com ele. O dinheiro estava com o réu, sendo em torno de R\$ 16,00 (fls. 117).

É importante salientar que a lei penal não furta valor ao testemunho dos agentes de segurança, na medida em que não os dispensa do compromisso de dizer a verdade e nem os poupa do crime de falso testemunho, caso venham a sonegar ou adulterar os fatos.

Há de se levar em conta que o acusado e os policiais não se conheciam até então, de forma que estes não tinham motivos para acusá-lo leviana e gratuitamente.

Aliás, nem teria sentido conferir-lhes a lei determinada tarefa para depois, quando viessem prestar contas de sua atuação, negar-lhes valor aprioristicamente, por preconceituosa admissão de que não dizem a verdade:

"É assente nesta Corte o entendimento de que são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito. Incidência do enunciado 83 da Súmula desta Corte" (STJ, Sexta Turma, AgRg no Ag 1158921/SP, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, julg. 17/05/2011, DJe 01/06/2011);

"O depoimento de policial obedece os mesmos princípios aplicados ao restante das pessoas, não havendo que se falar em suspeição ou inidoneidade considerando-se somente a sua condição funcional" (TJSP, RT 752/586);

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo sob garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam, com outros elementos probatórios idôneos" (STF, HC nº 74.608-0, Rel. Min. Celso de Mello, j. 18/02/97, DOU de 11/04/97, p. 189);

"Não se pode presumir em policiais ouvidos como testemunhas a intenção de incriminar falsamente o acusado da prática de crime contra a saúde pública na modalidade de tráfico de entorpecente por asseverarem que a substância tóxica foi encontrada em poder daquele. A presunção, ao contrário é de idoneidade destas testemunhas, ainda mais quando os seus depoimentos são seguros precisos e uniformes desde a sede inquisitorial e não há qualquer razão concreta de suspeição" (TJSP, RT

614/275);

“Os policiais não são proibidos de prestar depoimento nos processos de cuja fase policial tenham participado, seja efetuando a prisão do agente, seja apreendendo o objeto do crime. De outro lado, a declaração de inidoneidade é específica e não genérica, não podendo abranger toda uma categoria de pessoas, devendo ser alegada e demonstrada em cada caso” (TJMG, RT 604/407).

A partir do contexto probatório extrai-se que as testemunhas prestaram depoimentos coesos e convergentes, reafirmando as declarações prestadas na fase policial, tornando seguro um decreto condenatório.

E, não demonstrou a Defesa eventual motivo que os policiais teriam para mentir em juízo deixando, assim de se desincumbir de seu ônus (artigo 156, do Código de Processo Penal), destacando que eventuais e pequenas contradições entre os depoimentos, sequer existentes na hipótese, não são capazes de infirmar a lisura do trabalho policial. Nesse sentido:

“PROVA - Pequenas divergências entre os relatos das testemunhas - Irrelevância - Validade. As pequenas contradições na prova decorrem das próprias imperfeições do psiquismo humano, agravadas, em geral, pelas condições em que a prova é realizada. Assim, de se desconfiar do testemunho demasiado perfeito, sendo, sim, importante, verificar se, embora discrepantes em detalhes mínimos, concordam os depoimentos nos pontos essenciais, quanto às circunstâncias decisivas do fato” (TACrimSP - Ap. nº 583.153/2 - 7ª Câ. - Rel. José Habice - J. 05.04.90 - RJDTCRIM 6/78).

Tenta-se, em vão, diminuir o valor dos depoimentos dos policiais, o que não se sustenta diante do quadro probatório existente e dos elementos de convicção formados. Nesse ponto, é preciso ficar claro que a inexistência de testemunhas civis e 'eventuais compradores' no ato da prisão em flagrante não o invalida, cumprindo ressaltar que em delitos da espécie, como cediço, ainda que populares presenciem a atividade criminosa, estes não querem se identificar com medo de represálias por parte dos criminosos.

Dentro desse quadro, os depoimentos das testemunhas ouvidas sob o crivo do contraditório, repita-se, foram harmônicos e convergentes, corroborando a própria confissão, levando à certeza da autoria.

Sendo assim, a variedade, a quantidade e nocividade das drogas apreendidas, a forma como embaladas, bem como o depoimento seguro prestado pelas testemunhas, corroborado pela própria confissão, levam à certeza de que o réu traficava drogas na ocasião.

Destaca-se que o crime de tráfico de entorpecente é de mera conduta, bastando, para a sua consumação, a prática de qualquer um dos núcleos verbais do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, independentemente da concretização ou não da entrega ao destinatário, pelo que as simples condutas do réu, consistentes em “trazer consigo” e “ter em depósito” as substâncias entorpecentes, já são suficientes para caracterização do delito:

“Nunca é demais lembrar, de outro lado, que é desnecessária a prova de ato de comércio, bastando que o agente traga consigo ou mantenha em depósito a droga para esta destinação, ainda que futura, na medida em que a consumação não exige resultado” (TJSP - Apel. Crim. nº 990.09.088010-4 - 5ª Câmara Criminal - Campinas - v.u. - j. 03.09.09 - Rel. Des. Pinheiro Franco).

No mesmo sentido:

“O crime de tráfico de entorpecentes é configurado ainda que não haja venda de

tóxico, mas evidenciada somente a posse do produto destinado a consumo de outrem. Configurando crime de perigo abstrato, o tráfico não exige efetiva oferta da droga a terceiro, pois o bem jurídico tutelado é a saúde pública. É condenável a simples possibilidade de distribuição (gratuita ou onerosa) do entorpecente" (RT 776/663);

"Não é indispensável à prova efetiva do tráfico para a formação de um juízo de certeza, pois tal convencimento pode resultar satisfatoriamente comprovado pelo conjunto de indícios e circunstâncias que cercam o agente envolvido" (RT 729/542);

"Cabe ressaltar que para a caracterização do crime de tráfico de entorpecentes não é necessária a prova flagrante do comércio ilícito, sendo suficientes os elementos indiciais apurados no caso concreto, bem como as circunstâncias da prisão para evidenciar tal atividade ilícita". (TJ/SP - Apel. Crim. nº 990. 09.235417-5 - 14ª Câmara Criminal - v.u. - j. 11.03.10 - Rel. Des. Fernando Torres Garcia).

Como se vê, o réu confessou os fatos perante a autoridade policial (fls. 7) e também em juízo (fls. 118), revelando-se esta em consonância com as demais provas trazidas e colhidas sob o crivo do contraditório, tendo a jurisprudência se orientado no sentido de que, em regra, a prova constante do inquérito policial não deve ser desprezada.

As confissões, obtidas regularmente e ajustados seus termos com as demais circunstâncias ocorridas no caso, têm alto valor probante e podem ser aceitas se não elididas na fase judicial, como na hipótese.

A confissão deve ser avaliada pela força de convencimento que ela contém e não pelo local onde é prestada. Vale dizer, a confissão extrajudicial corroborada pela palavra da vítima e das testemunhas, bem como por outros elementos objetivos de prova, não pode ser invalidada pela retratação judicial, sem qualquer explicação plausível para a versão policial e com nova versão totalmente inverossímil. Inegável, assim, o valor probatório decorrente do entrosamento dos vários elementos de convicção (v. Código Processo Penal, arts. 6º, inc. V, 199, 197 e 157, combinados; JOSÉ FREDERICO MARQUES, Elementos de Direito Processual Penal, 1ª ed., Forense, 1961, vol. II, ns. 483 e 484, págs. 329-30; ADALBERTO JOSÉ Q. T. CAMARGO ARANHA, Da Prova no Processo Penal, 3ª ed., Saraiva, 1994, cap. XVIII, 4, pág., 195; RTJ, 81/337, 88/371, 90/750, 93/131, 95/563 e 143/306; RT, 421/267, 426/439, 507/417, 547/396, 549/358-390, 553/423, 569/289, 574/384, 578/374-402, 631/331, 675/395, 681/385, 689/439, 714/401, 715/481, 717/417, 724/712, 725/667 e 729/583; RJDTACrSP, 15/48, 19/75, 21/137-266 e 22/276; RJTJESP, 82/401 e 84/359; JTACrSP, 53/251, 56/197, 57/382, 61/242, 63/46, 64/26-293-294 E 66/263).

Nesse contexto, tem-se que deve ser acolhida a versão apresentada pelo acusado na fase administrativa, valendo destacar que nada há nos autos há infirmar a lisura dos trabalhos policiais:

"A confissão extrajudicial não deve ser desprezada quando se harmoniza e se ajusta à prova colhida na instrução, sob o crivo do contraditório, já que a confissão de autoria vale não pelo lugar em que é prestado, mas pela força de convencimento que nela se contém" (TJSP, RT 668/275);

"PROVA - Confissão extrajudicial - Valor - Prevalência desta sobre a retratação judicial - Inexistência de fatos que possam implicar no reconhecimento de falsa confissão na polícia - Depoimento em consonância com o restante do conjunto probatório - Condenação Possibilidade - Apelo parcialmente provido" (TJSP, 5ª Câmara de Direito Criminal, Apelação Criminal nº 1.097.136-3/8, Relator Pinheiro Franco, j. 30/08/07).

Ressalta-se que a considerável quantidade e variedade de entorpecente, além da forma como se deu sua apreensão demonstram a traficância e não autorizam eventual

classificação da conduta como simples consumo pessoal (artigo 28, da Lei nº 11.343/06):

“DESCCLASSIFICAÇÃO PARA DELITO DE USO - Inadmissibilidade - Quantidade e diversidade de entorpecentes - Conjunto probatório suficiente para ensejar o decreto condenatório - Inexistência de prova segura que autorizasse decretar nova definição jurídica da conduta.” (TJSP, 16ª Câmara de Direito Criminal, Apelação nº 990.08.080898-2, Des. Rel. Leonel Costa, j. 28/04/09).

E o fato de o acusado eventualmente afirmar que é usuário de droga, o que não se vislumbra, não é suficiente para a desclassificação do delito de tráfico, sendo, repita-se à exaustão, a condenação de rigor. Vale destacar, ainda, que a condição de usuário não é incompatível com a de traficante:

“(...) a mera condição de usuário ou dependente, por si só, não possui o condão de excluir a culpabilidade pelo narcotráfico, porquanto, em muitos dos casos, os usuários se valem dessa mercancia ilícita para provar o sustento do próprio vício, de tal forma, que uma conduta nem sempre pode excluir a outra.” (TJSP, AC nº 0000318-44.2016.8.26.0544, Rel. Des. França Carvalho, j. 05/04/2018).

“A alegação de viciado não obsta o reconhecimento da figura do traficante, mormente há hipótese vertente, em que ambas se mesclam num mesmo agente, preponderando a última, de maior gravidade” (TJSP RJTJSP 101/498);

“Importante consignar que o fato de o acusado ter declarado que era usuário de drogas não afasta sua condição de traficante, uma vez que os usuários, frequentemente, também passam a comercializar entorpecentes, justamente para obter dinheiro e garantir o vício e o próprio sustento, acrescentando-se, por oportuno, que uma conduta não exclui a outra” (TJSP; 9.ª Câmara Criminal, Ap. n.º 0001866-59.2015.8.26.0635, Rel. Sérgio Coelho, j. em 31.03.2016);

“Nenhuma incompatibilidade existe entre o tráfico de entorpecente e o vício. Ao contrário. Em regra, vivem associados” (RT 411/104).

Cabe observar, nesse passo, que a apreensão de não desprezível quantidade de substância entorpecente em poder do agente, além da circunstância de estar separada em unidades diferentes ou dividida em porções, conduz à segura conclusão de que se destina ao comércio ilícito, e não ao uso próprio.

Destarte, comprovadas a autoria e a materialidade, inexistindo causa de exclusão da ilicitude, a ação penal é procedente, amoldando-se a conduta praticada pelo réu à figura típica prevista no artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06.

Passo a dosar a pena:

Sopesados os elementos norteadores do art. 59, do Código Penal e em observância ao disposto no artigo 42, da Lei nº 11.343/06, que autoriza que o magistrado considere na primeira fase de dosimetria a natureza do entorpecente, a quantidade, a personalidade e a conduta social do agente, de rigor a fixação da pena-base acima do mínimo legal (v.g. STF, HC nº 96.655, rel. Min. Cármen Lucia; STF, HC nº 107.784, rel. Min. Ricardo Lewandowski; STJ, HC nº 237.837, rel. Min. Laurita Vaz; STJ, HC nº 235.524, rel. Min. Jorge Mussi; STJ, HC nº 223.447, rel. Min. Laurita Vaz; STJ, HC nº 179.086, rel. Min. Gilson Dipp). No mesmo sentido:

“REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. ELEVADA QUANTIDADE DO ENTORPECENTE APREENDIDO. POSSIBILIDADE. AUMENTO PROPORCIONAL. 1. Na fixação da pena-base de crimes previstos na Lei n. 11.343/2006, como ocorre na espécie, deve-se considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal, a natureza e a

quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei de Drogas. 2. Na espécie, a reprimenda de piso acima do mínimo legal, em razão da natureza e a excessiva quantidade do estupefaciente apreendido, encontra-se devidamente justificada e proporcional às especificidades do caso versado. [...] 2. Agravo regimental a que se nega provimento." (AgRg no AREsp 585.375/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 16/3/2017, DJe 27/3/2017);

O réu é tecnicamente primário e o antecedente criminal que possui (fls. 29/32) não é apto a macular a personalidade, contudo, na hipótese, foi localizado também com "crack" e cocaína, entorpecentes de alto poder viciante, que causam dependência física e psíquica, mesmo que utilizados apenas uma única vez, motivo que enseja uma maior reprimenda, pois seria desarrazoado punir aquele que vende "somente maconha" na mesma medida daquele que vende entorpecente altamente viciante, que além de causar um impacto muito maior na saúde do usuário, ainda repercute na sociedade e na família, somado ao fato de corroborar com a prática delitiva daqueles que não possuem condições financeiras de sustentar o vício.

Segundo o entendimento de Guilherme de Souza Nucci, "A Lei de Drogas baseia-se, principalmente, na punição de crimes de perigo abstrato, o que justifica destacar, como elementos preponderantes na individualização da pena, dentre outros, a natureza e quantidade da substância ou do produto. É natural supor que, quanto maior for a quantidade de drogas ilícitas em circulação, maior será o perigo em relação à saúde pública. Ademais, quanto mais forte for a droga ilícita, igualmente, mais grave será a consequência em virtude de sua utilização. Estes fatores, portanto, podem e devem ser levados em conta pelo magistrado" (in Leis penais e processuais penais comentadas, 4ª edição, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 378)

No mesmo sentido, defende Renato Brasileiro de Lima que "Como se trata de crime contra a saúde pública, quanto mais nociva a substância ou quanto maior a quantidade de droga apreendida, maior será o juízo de censura a recair sobre a conduta delituosa. De fato, não se pode equiparar a conduta daquele que é preso com um quilograma de maconha com a daquele que é preso com um quilograma de cocaína, já que esta droga tem um caráter viciante e destrutivo bem mais elevado que aquela" (in Legislação criminal especial comentada, 2ª edição, JusPODIVM, 2014, p. 787).

Registre-se que a cocaína é considerada um dos entorpecentes mais nefastos e viciantes, o que traz maiores danos à saúde pública, sendo de rigor a fixação da pena-base acima do mínimo legal, por ser proporcional à quantidade e natureza.

Assim, ponderando tal circunstância (natureza), fixo a pena-base com o acréscimo de 1/6 (um sexto), ou seja, em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Quanto à fração a ser aumentada, vale destacar não haver previsão legal valorando o quantum, ficando a critério do magistrado analisando o caso concreto: "o magistrado fixa a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto" (STJ, AgRg no REsp nº 143.071/AM, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 6/5/2015).

Prosseguindo, nos termos do artigo 68, do Código Penal, verifico presente a circunstância atenuante da confissão (artigo 65, III, "d", do Código Penal), razão pela qual retorno a reprimenda imposta ao seu mínimo, sendo nesta fase vedada a fixação abaixo do mínimo legal (Súmula 231, do STJ), perfazendo, pois 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Ausentes circunstâncias agravantes.

Na terceira fase, presente, a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, diminui a pena em 1/2 (metade), resultando em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.

Ainda que se reconheça seja o réu tecnicamente primário e não exista prova de íntegra organização criminosa, muito embora haja provas de que o réu se dedica a traficância, justifica-se a diminuição apenas em 1/2 (metade) em razão da variedade e da considerável quantidade da droga encontrada em seu poder (TJSP, Apelação nº 01049362.3/2, Des. Rel. Silveira Lima, j. 12/09/2007).

Esta pena torna-se definitiva, tendo em vista a inexistência de outras causas de aumento e de diminuição.

O valor do dia-multa deve ser calculado nos termos do artigo 43, da Lei nº 11.343/06, sendo fixado em um trinta avos do salário mínimo vigente à época do pagamento, tendo em vista a situação econômica do acusado.

No entanto, em que pese outro fosse o entendimento pessoal desta magistrada, curvou-me à recente decisão proferida no Habeas Corpus Coletivo nº 596.603/SP, do C. Superior Tribunal de Justiça (Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz) e fixo o regime aberto como modo inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade.

Afigura-se, no entanto, descabido falar em substituição da pena corporal por restritivas de direitos ou "sursis", porque não recomendáveis (artigos 44, III, e 77, II, do Código Penal).

Isto porque cuida de crime de natureza grave, de acentuada reprovabilidade e cujas circunstâncias e consequências impedem a substituição, sob o risco de a retribuição estatal ao ilícito tornar-se inócua. Em outras palavras, nem seria razoável que o réu, condenado por traficar entorpecentes extremamente nocivos à saúde humana, a desestabilizar o seio familiar e a vida em sociedade, venha a receber tratamento similar àquele agente que perpetra um delito de menor potencial ofensivo (TJSP, Apelação Criminal nº 1501495-39.2019.8.26.0228, 4ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Ivana David, j. 15/09/2020).

Vale lembrar que o chamado tráfico "privilegiado", previsto no §4º, do artigo 33, da Lei de Drogas, não é um tipo penal autônomo menos grave, mas sim causa de diminuição de pena, sendo certo que a minorante não tem o condão de alterar o próprio tipo penal do tráfico de drogas que, frisa-se, é crime grave.

A substituição, se deferida, faria com que a pena privativa de liberdade aplicada perdesse consideravelmente a sua força retributiva e preventiva, diante do gravíssimo delito de tráfico de drogas, levando em conta as especificidades do caso, como quantidade das drogas apreendidas e dedicação do réu a essa atividade criminosa.

Ademais, não vislumbro socialmente recomendável a reinserção de traficantes ao convívio social, indicando-lhes instituições públicas (escolas, repartições públicas, centros de saúde etc) para prestar serviços comunitários. Ausente, portanto, o requisito do inciso III, do art. 44 do Código Penal (suficiência da substituição).

O crime, frisa-se, é de especial gravidade, consistindo em causa ou consequência da prática de outros tão ou mais graves e intimamente ligados com a criminalidade violenta e com a desestruturação de inúmeras famílias. Os efeitos nocivos do crime de tráfico de drogas acarretam profundas feridas na sociedade atual, revelam a postura indiferente adotada pelo agente em relação à saúde pública e ao bem estar social, e as nefastas consequências de seus atos vão de encontro com o requisito previsto pelo inciso III, do artigo 44, do Código Penal, qual seja, "os motivos e

circunstâncias do crime indicarem que essa substituição seja suficiente”.

Assim, embora tenha sido praticado sem violência ou grave ameaça, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos não é cabível na espécie, uma vez que seria insuficiente à prevenção e repressão do ilícito penal.

Nesse sentido:

“(...) Por sua vez, a quantidade, diversidade e natureza das drogas constituem circunstâncias concretas que desnudam um elevado grau de culpabilidade, a impor o regime inicial fechado para a pena privativa de liberdade. O que também obsta a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito (artigo 44, I e III, do Código Penal), benefício, de resto, incompatível com a quantidade das sanções.(...)” (TJSP, 14ª Câmara de Direito Criminal, Apelação Criminal nº 1503722-19.2017.8.26.0536, Rel. Laerte Marrone, j. 30/01/2020)

“(...) a gravidade concreta da conduta do apelante, decorrente da quantidade de droga capaz de atingir um número não desprezível de usuários, revela a sua elevada danosidade social, a revelar óbice à substituição da pena corporal por restritivas de direitos, máxime porque estas não se mostram suficientes e socialmente recomendáveis (art. 44, III, CP). (...)” (TJSP, 13ª Câmara de Direito Criminal, Apelação Criminal nº 0000208-34.2016.8.26.0483, Rel. Moreira da Silva, j. 03/08/2017)

“(...) No entanto, com a devida vênia, o traficante, seja de pequeno, de médio ou de grande porte, não tem mérito para inicialmente cumprir a pena infligida de outra forma que não encarcerado. Ora, não se mostra razoável que o traficante, condenado por delito equiparado a hediondo (artigo 5º, inciso XLIII da Constituição Federal) venha a receber tratamento similar ao agente que perpetra um delito de menor potencial ofensivo. Em suma, não se mostra adequada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito em casos de tráfico de entorpecente, uma vez que tal medida atenta contra a efetividade do processo penal na aplicação do justo concreto, atingindo frontalmente o caráter retributivo da reprimenda e a dimensão material ou substancial do due process of law. (...) E, na espécie, como foram apreendidas 16 gramas de cocaína, droga de grande potencial ofensivo, a aplicação de pena alternativa encontra óbice na exegese do artigo 44, III do Código Penal, sendo insuficiente como resposta à culpabilidade do agente, aos motivos e às consequências do exercício da mercancia” (TJSP, Habeas Corpus nº 0049710-72.2012.8.26.0000, 4ª Câmara Criminal, Rel. Des. Euvaldo Chaib).

Ante o exposto e tudo mais que dos autos consta JULGO PROCEDENTE o pedido para condenar MARCELINO ALVES FERREIRA, qualificado nos autos, como incurso nas penas do artigo 33, "caput" c.c. §4º, da lei nº 11.343/06, fixando-lhe a pena privativa de liberdade de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, fixados no valor mínimo legal.

O réu poderá recorrer em liberdade, até porque assim respondeu ao processo e foi fixado regime inicial aberto, não havendo, ainda, razões para que seja decretada a sua prisão cautelar:

“I. Tendo o réu respondido ao processo em liberdade, o seu direito de apelar nesta condição somente lhe pode ser denegado se evidenciadas quaisquer hipóteses previstas no art. 312 do CPP, quando da prolação da sentença (Precedentes). II. Inexiste motivação convincente se não foi indicado qualquer fato novo que justifique a expedição de mandado de prisão (Precedentes). (...) Writ concedido.” (STJ, 5ª Turma, HC nº 51609/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 04/05/06, DJ 19/06/06, p. 161);

"1. A necessidade de recolhimento dos réus à prisão pra recorrer deve estar devidamente motivada, sendo insuficiente a mera consideração acerca do caráter hediondo ou da gravidade do delito. Precedentes do STJ e do STF. 2. Ordem concedida para garantir aos pacientes o direito de apelar em liberdade, expedindo-se alvará de soltura se por outro motivo não estiverem presos." (STJ, 5ª Turma, HC nº 46035/BA, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 15/12/05, DJ 10/04/06, p. 243).

Autorizo a incineração das drogas, nos termos dos artigos 50, §§ 3º e 4º e 72, ambos da Lei de Tráfico, destruindo-se amostras guardadas para contraprova. Comunique-se nos termos dos art. 524-A, § 2º, e 525, das NSCGJ, caso tal providência ainda não tenha sido adotada.

Nos termos dos artigos 63, I e § 1º, e 64, ambos da Lei nº 11.343/06, decreto o perdimento da quantia apreendida, assim como do objeto, pois decorrentes da prática do crime em questão. Oficie-se, após comprovação pela autoridade policial do depósito do referido valor nos autos, caso tal providência ainda não tenha sido adotada.

Na forma do artigo 804 do Código de Processo Penal e do artigo 4º, § 9º, alínea "a", da Lei nº 11.608/03, condenado, o réu arcará com as custas processuais:

"o réu, ainda que beneficiário da assistência judiciária gratuita, deve ser condenado ao pagamento das custas processuais nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, ficando, contudo, seu pagamento sobrestado, enquanto perdurar seu estado de pobreza, pelo prazo de cinco anos, quando então a obrigação estará prescrita, conforme determina o art. 12 da Lei 1.060/50. Precedentes. A isenção somente poderá ser concedida ao réu na fase da execução do julgado, porquanto esta é a fase adequada para aferir a real situação financeira do condenado, já que existe a possibilidade de sua alteração após a data da condenação" (REsp. 400.682, Rel. Min. Laurita Vaz, DJ 17/11/ 2003,). No mesmo sentido: REsp. 262.961, Rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, DJ 17.06/2002; REsp. 263.021, Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJ 18.03/2002 e REsp. 81.304, Rel. Min. Edson Vidigal, DJ 14/09/98. Diante do exposto, pelo meu voto, nega-se provimento ao recurso." – grifos nossos (TJSP, 4ª Câmara de Direito Criminal, Apelação nº 0008903-30.2009.8.26.0189, Relator Des. Euvaldo Chaib)

Expeça-se certidão de honorários à advogada nomeada nos autos (fls. 60), nos termos da tabela DPE/OAB vigente.

Após o trânsito em julgado oficie-se ao TRE, para fins do disposto no artigo 15, III da Constituição Federal; expeça-se guia de execução definitiva e arquivem-se os autos, com as anotações necessárias.

P.I.C.

Francisco Morato, 24 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA